

1500075-45.2021.8.26.0578

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa

Magistrado: LUCAS DADALTO SAHÃO

Comarca: Piraju

Foro: Foro de Piraju

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 15/08/2022

... Organização criminosa e associação ao tráfico. Insuficiência probatória para o édito condenatório. Corrupção passiva em relação ao acusado Glauco. Manutenção da absolvição por insuficiência probatória. Penas e regimes adequadamente fixados.

Recursos da acusação e defensivos improvidos. Sentença mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. (TJSP, Apelação Criminal nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piraju

Foro de Piraju

2ª Vara

Praça Joaquim Antonio de Arruda, 126, Piraju-SP - cep 18800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500075-45.2021.8.26.0578 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500075-45.2021.8.26.0578

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2020660/2021 - DEL.POL.PIRAJU, 15829962 - DEL.POL.PIRAJU, 77/21/118 - DEL.POL.PIRAJU, 2020660 - DEL.POL.PIRAJU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WAGNO DA SILVA LIMA e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS DADALTO SAHÃO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu DENÚNCIA contra WAGNO DA SILVA LIMA e DIÓGENES ELIAS GONÇALVES CARA LOPES (fls. 138/140), qualificados nos autos, dando-os como incurso nas sanções do art. 171, § 4º, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, e do art. 2º da Lei nº 12.850/2013, na forma do art. 69 do Código Penal, pela suposta prática dos seguintes fatos delituosos:

Consta do incluso inquérito policial que em local e data incertos, porém anterior a abaixo citada, WAGNO DA SILVA LIMA e DIÓGENES ELIAS GONÇALVES CARA LOPES, respectivamente qualificados a fls. 15 e 21, integraram, pessoalmente, organização criminosa.

Consta, ainda, que no dia 22 de janeiro de 2021, por volta das 11h39, na Rua Delfino Tossi, nº 60, Jardim Meira, na cidade e comarca de Piraju, os denunciados

tentaram obter, para os membros da organização criminosa, vantagem ilícita em prejuízo da vítima Lourdes Aparecida Carlin de Oliveira, idosa com 67 anos de idade, induzindo-a em erro, mediante ardil, não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades. (fl. 138).

A denúncia foi recebida em 26 de fevereiro de 2021 (fls. 154/155).

Devidamente citados, os acusados apresentaram respostas à acusação às fls. 189/191 e 435/437, por intermédio de defensores nomeados, combatendo o mérito da denúncia. Em não sendo o caso de absolver sumariamente os acusados, designaram-se audiências de instrução (fls. 451/452 e 490/491).

Nas datas aprazadas, foi colhida a prova oral, decretada a revelia do réu Wagno e encerrada a instrução processual (termos de fls. 490/491 e 522/523).

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência integral da pretensão punitiva, tecendo considerações acerca da dosimetria das penas (fls. 536/542).

A defesa de Diógenes pleiteou: (i) a absolvição em relação ao crime do art. 2º da Lei nº 12.850/2013, por se estar diante de mero concurso eventual de pessoas; e (ii) a incidência da atenuante da confissão espontânea no tocante ao delito de estelionato (fls. 546/548).

A defesa de Wagno, por sua vez, postulou a absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por não ter agido animado pelo dolo de praticar os tipos penais (fls. 549/550).

É o relatório. Fundamento e decido.

Inexistindo preliminares e/ou nulidades processuais a serem enfrentadas, passo diretamente à análise do mérito da demanda.

A materialidade delitativa está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), no boletim de ocorrência (fls. 3/6), no auto de exibição e apreensão (fls. 9/10 e 14), nos laudos periciais (fls. 175/179, 222/2225, 226/323, 325/422 e 423/426), no relatório de investigação (fl. 434), despontando, ainda, da prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Já a autoria é certa apenas em relação ao acusado Diógenes, pois a prova produzida em juízo não trouxe a tranquilidade e a segurança necessárias a fundamentar o edito condenatório em relação ao corréu Wagno.

A vítima, Lourdes Aparecida Carlin de Oliveira, ouvida em juízo (mídia audiovisual da primeira audiência), reiterou, em essência, a versão apresentada em solo policial (fl. 19). Declarou que: recebeu uma ligação do Banco do Brasil de uma mulher chamada Aline, perguntando se ela havia feito compra de R\$ 1.500,00 em uma determinada loja na cidade de Ribeirão; negou, ao que Aline lhe disse que o seu cartão havia sido clonado, mas que não era para ela se preocupar, porque a compra não fora confirmada; ficaram mais de 1h no telefone e, ao final, disse-lhe que deveria fazer uma carta descrevendo tudo o que ela havia lhe dito e entregar para um rapaz, de nome Waldo, juntamente com o seu cartão; após desligar o telefone, decidiu ligar para a funcionária do banco, que lhe informou que se tratava de golpe; ligou para a polícia e para sua filha; nesse meio tempo, o acusado Wagno chegou na sua casa, tocou a campainha e, como ela estava demorando, começou a chamá-la pelo nome; ela disse que estava com dificuldades para escrever, para ele esperar um pouco, enquanto estava ligando para a polícia; em seguida, sua filha e a polícia foram para a sua casa, momento em que encontraram o acusado Wagno em frente ao portão; nesse instante, foi até o portão e viu o acusado Wagno.

Tanto na fase inquisitiva (fl. 16), quanto em juízo (mídia audiovisual da primeira audiência), o policial militar João Paulo Aparecido Ferreira, compromissado, relatou que: foi acionado via 190 por solicitante que noticiava que havia recebido uma ligação de uma suposta funcionária do Banco do Brasil, informando que o cartão dela havia sido clonado e que o bando estava enviando um motoqueiro para retirar o cartão; foram até o Banco do Brasil, após foram à residência da vítima, e, pouco à frente, localizaram o acusado WAGNO, ao lado de uma motocicleta, realizando a abordagem; o acusado negou a prática delitativa, dizendo que só havia sido contratado para buscar o cartão; já, na delegacia, WAGNO informou que ele e o acusado DIÓGENES ELIAS estavam em uma pousada na cidade; então, foram até essa pousada, e, em contato com a recepcionista, foram informados de que o acusado DIÓGENES ELIAS havia acabado de sair do local; fizeram um breve patrulhamento nas proximidades e

localizaram o acusado DIÓGENES ELIAS sentado em um banco da praça; ao avistar a polícia, DIÓGENES dispensou um celular; com ele, dentro de uma bolsa, encontraram 3 máquinas de cartão, uma pequena porção de maconha e mais ou menos R\$ 300,00 em espécie.

O miliciano Robson José Valério, também compromissado, ouvido nas duas fases da persecução penal (fl. 18 e mídia audiovisual da primeira audiência), reproduziu, substancialmente, o relato do companheiro de farda João Paulo, minudenciando as diligências que resultaram na prisão em flagrante dos acusados.

Interrogado em solo policial, o réu Wagno da Silva Lima disse que: é de Sorocaba e há duas semanas foi contratado por um desconhecido para fazer a retirada de um objeto naquela cidade; não sabia de que objeto se tratava; o sujeito lhe pagou R\$ 50,00; na data dos fatos, novamente foi contratado pelo homem não identificado para vir à cidade de Piraju retirar um objeto que não sabia do que se cuidava no endereço passado; o sujeito lhe pagaria R\$ 50,00, além das despesas de viagem e hospedagem; ficou hospedado na Pousada Campos Verdes, onde também se encontrava Diógenes, o qual não conhece e não sabe o que ele estava fazendo; quando foi ao endereço indicado para a retirada do objeto, policiais militares o abordaram e o conduziram ao Plantão Policial; não sabia que se tratava de retirada de cartão bancário, tampouco participava de fraude de clonagem de cartão, apenas prestou o serviço para retirar o objeto, sem saber de mais nada; é usuário de maconha (fl. 15). Revel, restou prejudicado o seu interrogatório judicial.

Silente em solo policial (fl. 21), em juízo, o acusado Diógenes Elias Gonçalves Cara Lopes confessou a prática do estelionato. Narrou que: contratou o acusado WAGNO para buscar o cartão, mas ele não sabia sobre o delito; conheceu pessoas em São Paulo que o convidaram para participar do delito, e, pela situação difícil que estava passando, aceitou tomar parte na empreitada; ganharia R\$ 500,00 para cada cartão que conseguisse; era para praticar o crime somente em Piraju; eles deram dinheiro para que custeasse os gastos de hotel, alimentação e gasolina para que ele ficasse em espera, que eles entrariam em contato consigo; falou para o acusado WAGNO que prestaria serviço para uma empresa e precisava de um motoboy para fazer as retiradas dos documentos; o acusado WAGNO chegou a perguntar sobre o serviço, mas se limitou a dizer que não era necessário ele saber e que era referente a situações pessoais de clientes; ficou responsável por passar os cartões nas máquinas que lhe foram entregues; ele e Wagno ficaram no mesmo quarto, mas pedia para Wagno se retirar quando tratava sobre o crime (mídia audiovisual da primeira audiência).

Portanto a confissão judicial do acusado Diógenes, aliada aos seguros relatos da vítima e dos agentes públicos, forma quadro probatório convincente e bastante para lastrear a responsabilização criminal daquele.

Em contrapartida, o acervo probatório é sobremodo frágil no tocante à autoria ou participação do corréu Wagno na perpetração delitiva. A despeito de os indícios amealhados na fase pré-processual indicarem que ele havia se conluiado com Diógenes, os elementos informativos não foram corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e o alibi apresentado por Wagno na Delegacia de Polícia foi abonado pelo relato do acusado Diógenes.

Nesse panorama, não há qualquer ressaibo de nexu volitivo, de adesão voluntária de Wagno à conduta de Diógenes. Considerando que existem duas modalidades de concurso de pessoas, quais sejam, a coautoria (que se caracteriza pela existência de dois ou mais autores unidos entre si pela busca do resultado) e a participação (em que o partícipe não realiza diretamente o núcleo do tipo penal, mas de qualquer modo concorre para o crime), à luz do arcabouço probatório acima dedilhado, a atuação de Wagno apenas poderia ser esquadrihada como participação. Ocorre que os elementos de convencimento amealhados não acenam com a vontade consciente dele de colaborar com Diógenes, mediante induzimento ou instigação (participação moral), tampouco demonstram que ele prestou alguma forma de auxílio, facilitando, viabilizando a consecução da conduta descrita no núcleo do tipo penal (participação material) - até porque Diógenes admitiu ter agido conluiado com terceiros na perpetração delitiva.

Donde se conclui que a imputação relativamente a Wagno tem respaldo tão somente em

elementos informativos colhidos nos autos do inquérito policial, os quais não podem lastrear, por si sós, a responsabilização criminal, nos moldes do art. 155 do CPP. No âmbito processual penal, o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF) tem ressonância no brocardo do in dubio pro reo, impondo ao órgão acusador o ônus de provar os fatos por ele articulados na denúncia e a efetiva responsabilidade criminal do acusado (art. 156 do CPP). Como anotam EUGÊNIO PACELLI e DOUGLAS FISCHER:

Elementos informativos e elementos probatórios: Rigorosamente falando, o material produzido na fase de investigação não pode ser considerado prova. Ao menos, em princípio.

A fase de investigação, como se sabe, é destinada à formação do convencimento do órgão da acusação e não do magistrado. Na aludida fase, não há preocupação com o contraditório, até mesmo porque sequer se exerce a defesa do acusado. Não há ali, à evidência, ampla defesa. A partir de uma notitia criminis, avança-se para uma apuração sumária de seus elementos comprobatórios, sempre voltada para o convencimento do órgão responsável pelo juízo acusatório. Esse, o juízo acusatório, pode ser positivo, em que há o oferecimento da denúncia ou queixa, ou negativo, hipótese em que se requer o arquivamento da investigação, quaisquer que sejam os seus fundamentos.

Apenas o material produzido em Juízo é que, a rigor, constituiria prova, abrindo-se necessariamente ao contraditório e à ampla defesa, com efetiva participação da defesa. Em princípio, portanto, apenas a prova se prestaria ao convencimento judicial, não cumprindo essa missão os chamados elementos informativos da fase investigatória.

A nova redação do art. 155, trazida pela Lei nº 11.690/08, inova. E, para pior, a depender da extensão de sua aplicação.

Diz o texto: “não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. O que significaria isso?

Em primeiro lugar, é de se atentar para o fato de que a expressão “exclusivamente” não constava do anteprojeto original que veio a se transformar na Lei nº 11.690/08.

A ideia inicial era afastar qualquer possibilidade de valoração de material probante produzido unicamente na fase de investigação, ressalvadas as provas cautelares que não pudessem ser repetidas no curso da instrução (interceptações telefônicas, perícias em que já perecido o objeto da prova etc.). Com o acréscimo (do “exclusivamente”), levanta-se, mais uma vez, a questão acerca da possibilidade de formação de convencimento judicial com base em elementos informativos produzidos na investigação.

É de se ver, então, que a inexistência de contraditório e de ampla defesa na fase de investigação preliminar, em princípio, impede a valoração judicial de tais elementos (informativos). Como regra, é claro, já que existem provas, ressalvadas inclusive na citada Lei nº 11.690/08, cuja natureza intrínseca não permite a sua reprodução em juízo. Não se pode, por exemplo, reproduzir a conversa captada em uma interceptação telefônica. Do mesmo modo, não se realiza prova pericial quando o objeto a ser periciado já não se encontra mais à disposição. E, nada obstante, tais meios de prova são aceitos aqui e, provavelmente, na maioria esmagadora dos ordenamentos jurídicos.

É que, em tais situações, o contraditório é diferido, ou seja, é adiado – da fase de investigação para a fase de instrução – permitindo-se que a defesa levante objeções técnicas, do ponto de vista jurídico ou tecnológico, àquele material realizado sem o controle judicial. Por certo que a qualidade das objeções é reduzida, na medida em que se cuida de questionamentos pos factum, sem o alcance das percepções imediatas, em tempo real.

Mas, diante da relevância e da gravidade dos danos causados pela infração penal – eis aqui outra das inúmeras justificativas para um Direito Penal de intervenção mínima –, o Direito se curva à necessidade de flexibilização na interpretação até mesmo de garantias constitucionais.

A expressão “exclusivamente”, portanto, não deve ser entendida como uma porta aberta para a livre valoração do material produzido na investigação, se presentes outras provas colhidas na instrução criminal. Não. Fosse assim, o convencimento

judicial poderia ser construído com base essencialmente – e não exclusivamente! – em elementos informativos, bastando apenas a referência à existência de outras provas produzidas em Juízo.

Parece-nos que o tal “exclusivamente” apenas autorizaria um juízo de ponderação, de forma e principalmente de conteúdo, acerca das provas repetidas em Juízo, isto é, sobre a prova colhida na investigação e repetida em juízo. (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência – 12. ed. – São Paulo: Atlas, 2020. pp. 410/411). (Negritei).

Em suma: as provas não indicam o liame subjetivo em torno da participação de Wagno na empreitada delitiva, sendo impositivo absolvê-lo das imputações que lhe foram feitas, por força do disposto no art. 386, VII, do CPP.

Assentadas a materialidade e a autoria delitivas concernentemente a Diógenes, resta operar a qualificação jurídico-penal dos fatos.

Os fatos apurados amoldam-se à imputação do art. 171, § 4º, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal.

Como leciona PAULO JOSÉ DA COSTA JÚNIOR, no estelionato, “a conduta típica se divide em duas fases: num primeiro momento, a vítima é levada pela fraude ao engano; num momento subsequente, o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem indevida, causando ao ofendido um dano patrimonial correspondente. Do exposto se deduz a necessidade de um dúplice nexo de causalidade. Primeiramente, entre o meio fraudulento e o engano (efeito). Ao depois, entre o binômio erro-engano (causa) e o proveito injusto, com o correspondente dano (efeito).” (Comentários ao Código Penal – 7ª edição – São Paulo: Saraiva, 2002, p. 529). O elemento subjetivo é o dolo, acrescido do especial fim de agir, expresso na expressão “para si ou para outrem”; exige-se a finalidade de obtenção de lucro indevido, em proveito próprio ou alheio. O ardil (representação engenhosa que ilude o psiquismo alheio, causando um erro mediante a determinação, na pessoa iludida, de um convencimento, uma paixão ou emoção, criando motivos ilusórios com respeito à ação) empregado pelo acusado restou plenamente demonstrado pela prova vocal produzida nos autos. Ocorre que não houve o duplo resultado naturalístico da obtenção de vantagem ilícita, em proveito do réu e/ou de terceiros, e do prejuízo alheio (lesão ao patrimônio da vítima), de modo que não se consumou o estelionato, crime material e instantâneo.

Levando em consideração o iter criminis percorrido, reputo que o agente se aproximou de forma estreita da consumação do delito, de modo que a diminuição da pena pela tentativa deve ser no grau mínimo de um terço (art. 14, parágrafo único, do CP).

Ainda, o estelionato foi cometido contra idosa de 67 anos (fl. 19), concorrendo a causa de aumento do § 4º do art. 171 do Código Penal.

Noutro giro, é o caso de absolver o imputado da prática do crime do art. 2º da Lei nº 12.850/2013. A configuração desse tipo penal exige que ao menos quatro pessoas se agrupem de forma estável e permanente com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou que sejam de caráter transnacional. É a constatação desse vínculo subjetivo duradouro que se presta a distinguir o mero concurso eventual e episódico de pessoas do crime autônomo em tela. Como leciona RENATO BRASILEIRO DE LIMA:

Associação de 4 (quatro) ou mais pessoas: esta associação de 4 (quatro) ou mais pessoas deve apresentar estabilidade ou permanência, características relevantes para a sua configuração, que diferenciam esta figura delituosa do concurso eventual de agentes a que se refere o art. 29 do CP, dotado de natureza efêmera e passageira. Com efeito, apesar de não haver menção expressa no art. 2º da Lei nº 12.850/13, o ideal é concluir que a estabilidade e a permanência funcionam como elementares implícitas no crime de organização criminosa, porquanto não se pode admitir que uma simples coparticipação criminosa ou um eventual e efêmero acordo de vontades para a prática de determinado crime tenha o condão de tipificar tal delito. (Legislação criminal especial comentada: volume único – 9. ed. – Salvador: JusPODIVM, 2021, p. 788). (Negritado no original).

O Ministério Público não demonstrou o vínculo associativo estável, duradouro e

permanente entre o acusado e ao menos outros três comparsas, tampouco assinalou com qualquer relato de investigação anterior sólida e específica tendente a apurar a caracterização da *societas sceleris* entre eles, elucidando a ocorrência do delito do art. 2º da Lei nº 12.850/2013. Os elementos coligidos nos laudos periciais (fls. 175/179, 222/2225, 226/323, 325/422 e 423/426) e no relatório de investigação (fl. 434) e a prova oral supra dedilhada não são suficientes para comprovar a tese inaugural de que “a existência de pessoas com dados pessoais em nome da vítima, que praticam o ardil inicial via telefone, com a finalização pelos denunciados, que recolham o cartão de crédito para uso fraudulento, demonstra a existência de organização criminosa, com divisão de tarefas entre os seus integrantes para obtenção de vantagem financeira, mediante a prática de estelionatos” (fl. 139). Ainda que se conceda que “o laudo pericial no aparelho telefônico apreendido demonstra a familiaridade dos envolvidos diante das conversas mantidas com os integrantes da organização criminosa, bem como esclarecem parte do *modus operandi* dos criminosos” (fl. 539), o vínculo organizacional não é automático. As provas deveriam ter demonstrado a estabilidade e a permanência do agrupamento, parte dos seus membros (ao menos quatro), o papel por cada um desempenhado, não obstante a desnecessidade de haver habitualidade (cometimento reiterado das infrações penais). A associação não pode ser extraída de um fato isolado, requerendo, para sua comprovação, investigação mais apurada. O Estado precisa efetivamente investigar os fatos, não cabendo ao Poder Judiciário extrair de uma organizada empreitada delitativa a existência presunçosa de permanência e estabilidade de uma organização. Esse quadro de insuficiência probatória impõe a absolvição do acusado pela prática do crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, por força do princípio do *in dubio pro reo*. Nesse sentido:

APELAÇÃO. Peculato e corrupção passiva. Recursos da acusação e das defesas. Preliminares. Inépcia da denúncia. Violação do princípio do promotor natural. Não ocorrência. Preliminares rejeitadas. Mérito. Prova. Autoria e materialidade demonstradas. Manutenção da condenação dos réus Renato e Wagner pelo crime do artigo 317, § 1.º, do CP, em continuidade delitiva, e do acusado Glauco pelo delito do artigo 312 do CP. Organização criminosa e associação ao tráfico. Insuficiência probatória para o édito condenatório. Corrupção passiva em relação ao acusado Glauco. Manutenção da absolvição por insuficiência probatória. Penas e regimes adequadamente fixados. Recursos da acusação e defensivos improvidos. Sentença mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. (TJSP, Apelação Criminal nº 0027911-77.2016.8.26.0114, 2ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Luiz Fernando Vaggione, j. 24.08.2020).

Restou delineado, enfim, que o agente Diógenes praticou, consciente e voluntariamente, a conduta descrita no art. 171, § 4º, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal. Logo, ausentes excludentes de ilicitude, dirimentes de culpabilidade e causas de extinção da punibilidade, passo a dosar a pena aplicável a ele, em atenção ao sistema trifásico perfilhado pelo Código Penal (arts. 59 e 68). Na primeira fase, analisadas as circunstâncias judiciais alinhadas pelo art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade (grau de reprovabilidade ou juízo de censura) é normal à espécie. O réu ostenta duas condenações criminais anteriores transitadas em julgado, ambas por roubo, proferidas nos autos das ações penais nºs 0011058-64.2011.8.26.0050 e 0055642-51.2013.8.26.0050 (fls. 51/52), a primeira delas alcançada pelo período depurador delimitado pelo art. 64, I, do CP, de sorte que a valorarei nesta etapa como mau antecedente, forte no entendimento recente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema nº 150, RE 593.818/SC, j. 17.08.2020), e, a outra, na fase posterior da aplicação da pena, a título de reincidência, atento à dicção da Súmula nº 241 do STJ. Não há maiores informações sobre a conduta social (estilo de vida, correto ou inadequado, perante a sociedade, família, ambiente de trabalho etc.) e a personalidade (perfil subjetivo, nos aspectos moral e psicológico) do agente. O motivo, obtenção de lucro fácil, é inerente ao elemento subjetivo do estelionato. As circunstâncias (dados acidentais relativos à infração penal) e as consequências do crime (conjunto de efeitos danosos deflagrados pela infração penal) são próprias do tipo penal, no seu aspecto objetivo, não refugindo do ordinariamente verificado em delitos deste jaez.

E o comportamento da vítima (atitude do ofendido, que tem o condão de provocar ou facilitar a prática do crime) é circunstância neutra ou favorável.

À vista da presença de uma circunstância judicial desfavorável (mau antecedente), dentre as oito elegíveis pelo legislador, exaspero a pena-base em 1/8 (um oitavo), fixando-a em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo unitário (1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos), de vez que ausentes nos autos comprovação da capacidade financeira do acusado (arts. 49 e 60 do Código Penal).

Na segunda fase, concorrem a atenuante da confissão espontânea perante a autoridade judicial (art. 65, III, "d", do CP), consistente em "admitir contra si, por quem seja suspeito ou acusado de um crime, tendo pleno discernimento, voluntária, expressa e pessoalmente, diante da autoridade competente, em ato solene e público, reduzido a termo, a prática de algum fato criminoso" (NUCCI, Guilherme de Souza - Código Penal Comentado - 20. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 396), utilizada para a formação do convencimento deste julgador (Súmula nº 545 do STJ), e a agravante da reincidência (arts. 61, I, e 63, ambos do CP) - conforme acima se adiantou.

Atento à compreensão pacificada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do EREsp nº 1.154.752, em 26.05.2012, e a teor do art. 67 do CP, compenso integralmente a atenuante da confissão com a agravante, posto serem igualmente preponderantes, remanescendo a pena inalterada.

Na terceira fase, aplica-se a causa de aumento do § 4º do art. 171 do Código Penal, de modo que procedo à majoração de 1/3 (um terço), passando a dosar a pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

De outro lado, há de ser reconhecida a modalidade tentada do delito (art. 14, II, do Código Penal), razão pela qual diminuo a pena no patamar mínimo legal de 1/3 (um terço) - conforme motivado acima -, tornando-a definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 9 (nove) dias-multa, no valor mínimo unitário (1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos).

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena corporal, porquanto se trata de réu portador de mau antecedente e reincidente (art. 33, §§ 2º e 3º, do CP).

Inviáveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, em razão do mau antecedente e da reincidência do acusado (arts. 44 e 77 do CP, a contrario sensu).

Por fim, em que pese seja indigesta a aplicação da detração nesta etapa processual - tarefa relegada, no mais das vezes, ao juízo das execuções penais -, o réu teve a sua prisão preventiva decretada em 23.01.2021 (fls. 77/81). De lá para cá já transcorreram mais de 1 ano e 7 meses. Assim, o acusado está preso provisoriamente há tempo demasiado (muito superior ao da pena ora imposta), estando em situação mais gravosa do que o regime ora fixado. Diante dessa sutileza, sopesado o tempo de prisão cautelar imposta ao imputado, aplico a detração anômala, com fulcro no art. 42 do Código Penal, para o fim de declarar extinta a sua punibilidade pelo cumprimento integral da pena imposta. Nesse rastro já se posicionou o Tribunal de Justiça de São Paulo em hipóteses propínquas:

Receptação, furto qualificado e corrupção de menor - Desistência voluntária quanto ao furto reconhecida pelo juízo menorista, a implicar na absolvição dos réus por tal delito nesta esfera penal, assim como pela corrupção de menor, a fim de se evitar a coexistência de decisões conflitantes - Necessidade de se resguardar a segurança jurídica - Efeitos estendidos ao corréu não apelante, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal - Manutenção, todavia, da condenação pela receptação - Posse de veículo sabidamente produto de ilícito comprovada - Dolo direto depreendido dos elementos constantes dos autos - Absolvição descabida - Pena arbitrada com critério - Reincidência específica que torna inviável a substituição da carcerária por restritivas de direitos - Regime semiaberto, todavia, que melhor se afina à hipótese - Aplicação da detração anômala devida - Cumprimento da pena - Apelo provido em parte, com reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade. (Apelação Criminal nº 1513588-34.2019.8.26.0228, 13ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Marcelo Gordo, j. 15.12.2021); e

Apelação. Ameaça. Violência doméstica contra a mulher. Recurso defensivo. Insuficiência probatória. Inocorrência. Pena reduzida. Regime inicial semiaberto que se mostra necessário para reprovação e prevenção do crime. Réu preso provisoriamente por período superior ao da condenação. Detração anômala. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. Declarada extinta a punibilidade do apelante em razão do cumprimento da pena imposta. (Apelação nº 0002226-11.2014.8.26.0091, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Leme Garcia, j. 11.08.2015).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia para: (a) ABSOLVER o acusado WAGNO DA SILVA LIMA, já qualificado nos autos, das imputações que lhe foram feitas por incurso nas sanções do art. 171, § 4º, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, e do art. 2º da Lei nº 12.850/2013, na forma do art. 69 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; (b) ABSOLVER o acusado DIÓGENES ELIAS GONÇALVES CARA LOPES, também já qualificado nos autos, da imputação que lhe foi feita por incurso no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e (c) CONDENAR este acusado como incurso no art. 171, § 4º, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, às penas de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial fechado, e 9 (nove) dias-multa, no valor mínimo unitário (1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos). De ofício, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da pena imposta, pelo seu cumprimento integral.

Expeça-se alvará de soltura para que o acusado seja colocado imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

Em razão do presente desfecho decisório, ORDENO a cessação das medidas cautelares fixadas na decisão de fls. 77/81 em desfavor de Wagno (art. 386, parágrafo único, II, do CPP).

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pelas infrações (art. 387, IV, do CPP), quer porque a conduta não teve repercussão patrimonial, quer porque não há elementos bastantes para o arbitramento de eventual indenização por dano moral.

Condeno o réu Diógenes, ainda, ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP). Contudo, a respectiva exigibilidade ficará suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da dicção conjunta dos arts. 3º do CPP e 98 a 102 do CPC, pois ora lhe concedo o benefício da assistência judiciária gratuita.

Intime-se a vítima do teor deste julgado (art. 201, § 2º, do CPP).

Expeçam-se certidões de honorários em favor dos nobres patronos nomeados no valor máximo previsto na tabela vigente.

Sobrevindo o trânsito em julgado: (a) lance-se o nome do réu Diógenes no rol de culpados; (b) oficie-se ao TRE do domicílio eleitoral do acusado para fins de suspensão dos direitos políticos (art. 15, III, da CF) e para efeitos de inelegibilidade; e (c) oficie-se ao IIRGD, para fins de registro dos antecedentes criminais do acusado.

Oportunamente, arquivem-se definitivamente os autos, promovendo-se as baixas nos registros.

P. I. C.

Piraju, 15 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA